

1503219-59.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... de praticar, reiteradamente ou não, tráfico de drogas, mediante divisão de tarefas.

Narra a acusação o acusado se associou com as adolescentes Victoria e Yasmin para cometerem crimes de tráfico de drogas, de modo que ele pudesse permanecer no local escolhido sem atrair a atenção da polícia, pois aparentaria estar apenas conversando com as jovens. Na data dos fatos, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1503219-59.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503219-59.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEMERSON MORAIS DE SOUZA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

WEMERSON MORAIS DE SOUZA, qualificado no autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 35, caput, c.c. art. 33, caput, ambos c.c. art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, porque no dia 18 de dezembro de 2021, por volta das 14:50 horas, na Rua Quatro, 560, Parque Rodrigo Barreto, agindo em concurso com as adolescentes Victoria Karolina Pinto Lopes e Yasmin Vitoria das Neves José, transportava, guardava e expunham à venda 42 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 20,4 gramas, 71 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 2,6 gramas e 17 invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de 24,2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico, droga essa que causam dependência física e psíquica. Ainda, conforme a denúncia, desde data não determinada até o dia 18 de dezembro de 2021, o acusado e as adolescentes Victoria Karolina Pinto Lopes e Yasmin Vitoria das Neves José, ambas com 16 anos de idade, associaram-se entre si para o fim de praticar, reiteradamente ou não, tráfico de drogas, mediante divisão de tarefas.

Narra a acusação o acusado se associou com as adolescentes Victoria e Yasmin para cometerem crimes de tráfico de drogas, de modo que ele pudesse permanecer no local

escolhido sem atrair a atenção da polícia, pois aparentaria estar apenas conversando com as jovens. Na data dos fatos, o acusado estava na via pública, em local conhecido como ponto de traficância, em companhia das adolescentes Victoria e Yasmin. Ao notar a presença da polícia, o acusado entregou uma bolsa para Yasmin e tentou evadir-se do local com as mãos dadas com Victoria, mas foram alcançados e abordados por policiais. Durante a revista pessoal, com o acusado foi encontrada a quantia de R\$ 10,00, mas com a adolescente Yasmin foi encontrada a bolsa entregue pelo acusado, na qual havia os entorpecentes acima aludidos e a quantia de R\$ 301,00. Com a adolescente Victoria havia a quantia de R\$ 240,00. As duas adolescentes afirmaram que estavam vigiando e tomando conta do local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, e que para tanto receberiam R\$ 50,00.

Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 01. Boletim de Ocorrência às fls.08/11. Auto de exibição e apreensão às fls.12/13. Laudo de constatação (fls.15/17). Laudo de exame toxicológico definitivo às fls. 97/99 e 152/154.

A decisão de fls. 64/67 converteu o flagrante em prisão preventiva ao acusado, em 19/12/2021.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar às fls. 122/132.

A denúncia foi recebida em 01/07/2022, às fls. 137/138.

Folha de antecedentes do acusado às fls. 187/189.

Em audiência foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado (fls. 203/206).

O Ministério Público em alegações finais orais, pugnou pela parcial procedência da denúncia, não se comprovando estabilidade de agentes para a configuração de associação para fins de tráfico. Alegou que em relação ao delito de tráfico de drogas há prova suficiente para a condenação. Quanto à dosimetria, altercou que a culpabilidade é anormal, pois as adolescentes são trazidas de outra cidade para disfarçar a atuação do acusado. O delito foi praticado em concurso de três pessoas, o que é desfavorável. Alegou que o réu possui antecedentes, sendo condenado definitivamente e é reincidente específico em tráfico de drogas e por uso de entorpecentes. O uso de entorpecentes deve ser utilizado como circunstância desfavorável do acusado e o trânsito em julgado ocorreu antes dos fatos destes ora apurados. A reincidência deve ser valorada em segunda etapa. Sustentou que a diversidade de drogas e natureza destas deve causar aumento nos termos da Lei de Drogas. Na segunda etapa deve a menoridade relativa ser compensada com a reincidência. Afirmou que há ardil utilizado pelo acusado em tentar dispensar a droga fingindo ser namorado da adolescente. Na última etapa incide a causa de aumento por atuação conjunta com menores de idade, devendo o aumento ser no mínimo de 1/3 (1/6 para cada adolescente). Afirmou que não cabe o reconhecimento de tráfico privilegiado. Pugnou pela fixação e regime fechado, não cabendo a substituição por restritiva de direitos.

Em alegações finais de fls. 193/198, a defesa do acusado requereu a absolvição do acusado, ante a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de porte para uso próprio.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada conforme boletim de ocorrência, laudo de constatação e prova oral colhida.

Autoria de tal delito segue a mesma sorte.

Em relação ao delito de associação para fins de tráfico, contudo, inexistem provas de materialidade e autoria delitiva.

Passo à análise da prova oral colhida no feito:

A testemunha Claudinei Ramos da Silva, policial militar, declarou que na data dos fatos estavam patrulhando o local e avistaram o réu descendo a rua com duas moças. Ele entregou uma bolsa a elas e fizeram a abordagem. Com ele nada havia de ilícito e na bolsa entregue às meninas havia substância entorpecente e dinheiro. Com a outra moça havia dinheiro, em torno de R\$ 200,00 em notas trocadas. Afirmou que viu o réu descendo a rua com a adolescente e ele entregou a bolsa a uma delas, que colocou a bolsa por baixo da roupa.

A testemunha Rafael da Silva Ferreira declarou que na data dos fatos estavam em local conhecido como ponto de drogas, na rua 04, e avistaram 3 pessoas em direção à viela. O acusado entregou uma bolsa a duas jovens e abordaram a todos. Na bolsa havia entorpecentes e com a moça havia dinheiro. Afirmou que conversaram com as adolescentes no momento da abordagem e o réu era o responsável pela coleta financeira e elas eram de outro município, de Itaquá, e frequentavam essa cidade com esse intuito. O acusado estava de mãos dadas com uma delas, que não se recorda com qual. As adolescentes estavam trabalhando para o tráfico, vindo de outra cidade para esse fim e como mulher não chama atenção, disfarçavam o tráfico de drogas no local. Disse que a rua 4 é extensa e bem visível. O réu caminhava em direção à viela ao final da rua. O acusado estava com dinheiro, sendo ele que passou a bolsa com a droga. Não sabe da vida pregressa do acusado.

O réu Wemerson Moraes de Souza declarou em interrogatório judicial que tem 21 anos, trabalha com seu tio numa transportadora, ia ser registrado e ganhava um salário mínimo por mês. Estou até o primeiro ano do segundo grau. Não tem filho. Já foi processado como usuário de drogas, em 2019 e teve outro processo em 2020. Disse que tinha acabado de sair da cadeia e tinha ido comprar drogas. Não correu da viatura e o policial lhe deu papéis para assinar, foi oprimido na delegacia e assinou os papéis. Disse que foi na adega e comprou cigarro. Viu duas meninas vindo e desceu a rua com elas, e ia pegar um "pó" com elas". A viatura apareceu. Não correu e ficou parado. O policial abordou as meninas e foi abordado. Não chegou a comprar as drogas com as meninas e eram as duas que tinham as drogas, pois viu um rapaz comprando drogas com elas. Afirmou que as moças eram estranhas ao seu convívio e somente as viu nessa vez. Não sabia o nome dessas meninas.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

De início, impõe-se absolver o réu pelo crime de associação para o tráfico, conforme requereu o próprio Órgão Ministerial em sede de alegações finais.

Isto porque, não restou devidamente demonstrado no caso em tela a prática do delito de associação para o tráfico, eis que os elementos probatórios são insuficientes à certeza de sua ocorrência.

Como é cediço, o crime do art. 35 da lei 11.343/2006 é uma espécie de quadrilha ou bando específico do tráfico ilícito de entorpecentes, exigindo para a sua configuração a comprovação de sua permanência. Afirma Guilherme de Souza Nucci (2009, p.365):

"Demanda-se prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa." E mais: "exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no animo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática de crime de tráfico."

No caso em testilha, não tendo sido comprovado o caráter de estabilidade e permanência da associação, não há como se imputar ao acusado a prática do crime em questão, que conforme a denúncia teria sido cometido com as adolescentes Victoria e Yasmin, não tendo, desta feita, se desincumbido o Ministério Público do ônus probandi que lhe é imposto.

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça:

Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343.2006". (HC 349837/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, v.u., j. 03.05.2016. No mesmo sentido REsp 1501842/PR, 6ª Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, v.u., j. 05.04.2016).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE APONTAVAM NOMINALMENTE AS PESSOAS DOS RÉUS COMO TRAFICANTES - APREENSÃO DA DROGA EM LOCAL PRÓXIMO - ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - TESES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - RECURSO MINISTERIAL - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO - MANUTENÇÃO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 - POSSIBILIDADE. - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se de qualquer outra testemunha fossem, eis que prestam compromisso e estão sujeitos às penalidades legais pelo falso, mostrando-se hábeis, portanto, a confirmar os fatos expostos no flagrante e comprovar a autoria delituosa. - Tendo os policiais recebido denúncia anônima apontando as pessoas dos réus como traficantes, e sendo eles abordados em lugar conhecido como ponto de venda de drogas, apreendida em local próximo elevada quantidade de entorpecentes, deve ser mantida a condenação. - Para caracterização do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06, deve ser comprovada a estabilidade e permanência do vínculo associativo, não demonstradas no presente caso, mantendo-se a absolvição declarada na sentença. (TJ-MG - APR: 10079073229183001 MG, Relator: Delmival de Almeida Campos, Data de Julgamento: 15/05/2013, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/05/2013, undefined)

Como mencionado alhures, mesmo que entendêssemos estarmos diante de alguns indícios de associação, isso não deve bastar para caracterizar a culpabilidade do réu pelo delito em questão, especialmente quando toda a investigação não veio acompanhada de uma apuração mais rigorosa destas circunstâncias.

No caso, pode-se até cogitar de probabilidade do crime de associação, mas o fato é que, "no processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio." (RT 619/267).

Outrossim, para configuração do delito de associação não se exige que os componentes da associação se conheçam e que haja nítida divisão de funções. Basta, apenas, que a associação vise à prática de um número incerto de crime, por tempo indeterminado (elemento subjetivo do tipo). No caso dos autos, todavia, a presença de vínculo estável e psicológico entre o réu e as duas adolescentes não restou evidenciada pelas provas produzidas.

Registre-se que não houve investigação prévia sobre a atuação do acusado e das adolescentes, ou mesmo posterior, que pudesse confirmar o vínculo associativo descrito na exordial acusatória. Ademais, o próprio réu negou a associação, dizendo que não conhecia as adolescentes e somente foi ao encontro destas para adquirir drogas para seu uso.

Ainda, não foram encontrados com o acusado e com as adolescentes anotações, balança ou outros insumos que pudessem revelar ou confirmar uma ligação estável e permanente entre eles para prática reiterada de crimes, nem mesmo de tráfico.

Em relação ao crime de tráfico, contudo, o desfecho dos autos é outro.

Os policiais ouvidos em juízo informaram como se deu a prisão do réu e o encontro das drogas, alegando que o réu estava com as duas adolescentes e quando viu a viatura de polícia entregou bolsa contendo as drogas para uma das adolescentes, tentando disfarçar sua ação, ainda, dando as mãos para outra adolescente.

O acusado, por seu turno, negou o cometimento de tráfico, alegando que é usuário de drogas e foi ao local para adquirir entorpecentes e que as adolescentes eram pessoas estranhas ao seu convívio, mas sabia que elas estavam com drogas por ter visto indivíduo adquirindo com elas o entorpecente.

O réu, em delegacia, apresentou a mesma versão dos fatos (fls. 07), apesar de alegar em juízo que foi "oprimido" por policiais, que teriam lhe dado papéis para assinar.

Vê-se que o exame toxicológico confirmou a natureza entorpecente das drogas localizadas (fls. 97/99 e 152/154).

Em delegacia (fls. 05/06) as adolescentes Victoria e Yasmin negaram conhecer o acusado, confirmando que estavam vigiando e "tomando conta" da biqueira, e que receberiam R\$ 50,00 por tal ato. Não mencionaram de quem receberiam R\$ 50,00 para vigiar o ponto de venda de drogas.

Nota-se que ante a prova existente nos autos o réu deve ser condenado pelo delito de tráfico de drogas.

Cabe observar que embora o réu tenha negado a propriedade da droga, afirmando que tinha saído para adquirir drogas para seu uso próprio, que não conhecia as adolescentes, e não portava as drogas apreendidas pela polícia, sua versão não é digna de credibilidade.

Saliente-se que os próprios policiais afirmaram que o local é bem conhecido como ponto de venda de drogas e os policiais teriam visto o acusado entregar a bolsa com as drogas às moças e depois, descer a rua de mãos dadas com uma delas.

O acusado justificou a razão de estar no ponto de venda de drogas que seria a aquisição de drogas, após ter comprado cigarros, mas não trouxe quaisquer testemunhas para corroborar sua versão dos fatos.

E é importante salientar que em delitos de tráfico de drogas, cometidos, normalmente, na clandestinidade, a prova, em regra, é composta por depoimentos dos policiais, que de modo geral, são suficientes a demonstrar a culpabilidade de um réu, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos, como ocorre no caso em tela, visto que a tese defensiva não se revelou robusta o suficiente para contrapor a tese acusatória.

No caso dos autos, o conjunto probatório é robusto e idôneo para o reconhecimento da culpabilidade do réu, porque ao lado dos depoimentos policiais, há a apreensão

do entorpecentes em bolsa que os policiais presenciaram ser entregue à adolescente.

Embora as adolescentes tenham negado em delegacia conhecerem o acusado, confirmaram que estavam na biqueira para tomar conta desta, vigiando-a, e nada mencionam em depoimento sobre a bolsa contendo drogas.

Com efeito, embora não se possa utilizar elementos do inquérito policial como prova, no caso em questão, é a própria versão do acusado em juízo que, contraposta aos relatos dos policiais e às demais provas colhidas, termina por conduzir à certeza de culpabilidade.

Tem-se que a própria versão do réu em juízo não se revela crível, sendo confirmado por ele próprio que estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e foi em direção às adolescentes. Portanto, não trouxe o acusado aos autos qualquer elemento de prova passível de gerar alguma dúvida no tocante a sua culpabilidade, captando o convencimento do magistrado, e com isso, ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Este juízo vem sempre consignando que não seria demais exigir do órgão acusador, a quem se impõe o ônus probandi, a juntada de outras provas que não se limitem às declarações dos policiais que foram responsáveis pela prisão do agente, e que hoje já existem outros instrumentos e mecanismos aptos a robustecer os motivos ensejadores da prisão e da persecução penal, como gravações audiovisuais para registrar as abordagens, diligências e operações. Não obstante, as circunstâncias específicas do caso, mormente em relação às declarações contraditórias do acusado, ao mencionar que policiais lhe fizeram assinar papéis, oprimindo-o, não tendo, contudo, em delegacia, segundo interrogatório assinado pelo próprio acusado, confessado o delito, revelam uma versão defensiva muito frágil e pouquíssimo convincente, a qual, por sua vez, acaba oferecendo elementos sobre a abordagem que se coadunam com a dinâmica relatada de forma uníssona pelos policiais, terminando por constituir um conjunto probatório suficiente à prolação de um decreto condenatório em desfavor do acusado.

Recorda-se, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, de modo que se consuma com qualquer das outras condutas descritas no mencionado dispositivo legal, como, transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entregar a consumo e fornecer drogas, ainda que gratuitamente.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE QUE A PROVA OBTIDA NOS AUTOS É ILÍCITA, E DE QUE O CRIME É IMPOSSÍVEL, POR NÃO TER CHEGADO AO DESTINO, QUE NÃO FORAM VENTILADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDUTA DE TRANSPORTAR OU TRAZER CONSIGO, COM O INTUITO DE FORNECER, AINDA QUE PARA GRATUITO CONSUMO ALHEIO, QUE SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. [...] 2. "Transportar", "trazer consigo" ou "fornecer ainda que gratuitamente" substância entorpecente ilícita são São Paulo núcleos do tipo do delito de tráfico de drogas - crime de perigo abstrato, de ação múltipla e conteúdo variado, que se consuma com a prática de quaisquer das ações insertas no art. 33 da Lei Antidrogas. (HC 225555/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 09/12/2012).

Vê-se que a prova amealhada durante a instrução penal é suficiente para o reconhecimento do crime de tráfico pelo acusado.

Conforme a folha de antecedentes de fls. 187/189, é inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, por ser o réu

reincidente, tendo duas condenações por tráfico de drogas e porte para uso próprio transitadas em julgado.

Ainda, incide a causa e aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas, pois o acusado cometeu o delito conjuntamente com as duas adolescentes Victoria e Yasmin, que confirmaram trabalhar na "biqueira".

Por fim, inviável a desclassificação para o delito de porte para uso próprio, pois há prova suficiente para a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas, conforme exposto acima.

Ainda, inexistente qualquer causa excludente de ilicitude ou que isente o réu de pena em relação ao delito de tráfico.

No mais, a ação foi culpável, reprovável, pois o réu era (e ainda é) ao tempo da conduta imputáveis, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu WEMERSON MORAIS DE SOUZA, como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, ABSOLVENDO-O, todavia, das imputações relativas ao delito do art. 35, da Lei de Drogas, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena do réu.

Circunstâncias judiciais

Assim, primeiramente, no tocante às circunstâncias judiciais, verifico que o réu agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar nesse sentido. Não há nos autos elementos concretos que permitam uma valoração da sua personalidade. O réu possui maus antecedentes (fls. 187/189), pois possui duas condenações transitadas em julgado, devendo uma delas ser valorada como maus antecedentes. O motivo do delito se constituiu pela obtenção do lucro fácil, que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Nada há, em concreto, que desabone a sua conduta social. As consequências do crime não se mostraram de maior monta. As circunstâncias também não se revelam desfavoráveis ao acusado, lembrando que a quantidade e natureza da droga não apresentam expressão ou magnitude aptas a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Diante de tais considerações fixo a pena-base no mínimo legal, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 562 dias-multa, no menor valor legal.

Na segunda fase incide a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência.

A menoridade relativa, conforme entendimento remansoso da jurisprudência, é circunstância preponderante, nos termos do art. 67, do CP ("No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência").

Neste sentido:

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a reincidência e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes, consoante disposto no art. 67 do Código Penal, devendo ser mantida a compensação integral entre as referidas circunstâncias legais operada na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, nos moldes do reconhecido no decreto

condenatório. Precedentes” (AgRg no HC 497.101/SC, 5ª Turma, j. 06/06/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 16, LEI 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – In casu, não se vislumbra, na espécie, potencialidade lesiva mínima que pudesse justificar a condenação, a absolvição do acusado da imputação contida no art. 16, da Lei nº10.826/2003 é de rigor. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – Impossibilidade. Demonstradas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecente, de se manter a condenação do agente, decretada em primeiro grau. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 – Impossibilidade. Descabida a desclassificação para uso, quando a prova dos autos demonstra de forma indubitosa a autoria e a materialidade delitiva do tráfico de drogas. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA – Acusado que não tinha 21 anos completos à data dos fatos faz jus à atenuante da menoridade relativa que deve ser compensada com a agravante da reincidência, por serem ambas igualmente preponderantes. Penas redimensionadas. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500309-23.2018.8.26.0484; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Promissão - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022)

Portanto, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, mantendo a pena-base acima fixada.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas, em razão de o delito ser cometido conjuntamente com duas adolescentes, razão pela qual aumento a pena do acusado em 1/6, não havendo que ser computado na forma como requerido pelo Ministério Público (1/3, sendo 1/6 para cada adolescente em aumento), incidindo o aumento no patamar mínimo pela presença de menores durante o ato criminoso.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. Artigo 33, caput, c.c. o 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito de absolvição ou de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal. Materialidade e autorias devidamente comprovadas nos autos. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese defensiva. Depoimentos de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Condenação mantida. Dosimetria que merece pequeno reparo. Redução da fração de aumento eleita para agravar a pena em razão da circunstância agravante da reincidência, uma vez que o legislador não conferiu tratamento mais rigoroso à reincidência específica. Pena readequada. Prova dos autos que demonstra o envolvimento de dois adolescentes na prática ilícita. Escorreita a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, com acréscimo na sexta parte. Regime inicial fechado adequado à espécie. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500531-45.2020.8.26.0411; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pacaembu - 2º Vara; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

1-) Apelações criminais. Provimento parcial dos recursos defensivos, para redimensionamento das penas, com redução... O envolvimento de adolescentes tampouco pode ser considerado nesta etapa, pois se trata de causa de aumento, a ser observada na terceira fase da dosimetria, nos termos do art. 40, VI, da Lei n.

11.343/06 c. Essa foi a opção legislativa. Na segunda fase, quanto ao sentenciado Arthur, em razão da reincidência, processo nº 0012034-72.2008.8.26.0019, conforme certidão de fls. 893, agrava-se de 1/6, tendo-se sete (7) anos de reclusão e setecentos (700) dias-multa. Afasta-se, por outro lado, a agravante disposta no artigo 62, I, do Código Penal, pois não ficou comprovado que dirigia a atividade dos demais agentes, sendo certo que alguns policiais sequer o conheciam, mas apenas Iraílson como comandante da traficância no bairro. Quanto a Iraílson, a sanção fica inalterada, afastando-se a reincidência reconhecida em primeira instância, pois o processo mencionado pelo douto magistrado, qual seja 1500357-91.2018.26.0189, conforme certidão de fls. 902, transitou em julgado para a Defesa apenas em 17.9.2020, ou seja, após o fato em estudo. Na terceira fase, não pode incidir a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, nos termos do próprio dispositivo, não se podendo descartar, diante das circunstâncias do caso concreto, reiteração criminal. Adolescentes estavam envolvidos. São jovens que, se virem os apelantes impunes ou não sendo apenados devidamente, ficarão motivados a trilharem o mesmo caminho, justificando o aumento de 1/6, nos termos do art. 40, VI, da Lei de Drogas, tendo-se oito (8) anos e dois (2) meses de reclusão e pagamento de oitocentos e dezesseis (816) dias-multa, para Arthur e sete (7) anos de reclusão e setecentos (700) dias-multa, para Iraílson. As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica. 5-) O regime inicial das penas corporais é o fechado. Os apelantes denotam, pois, periculosidade, ousadia, personalidades desvirtuadas e condutas sociais impróprias, não respeitam os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar outrem". Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorram mais e proporciona-se que reflitam sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia. 6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. 7-) A substituição das penas corporais por restritiva de direitos não é possível. O valor da sanção é superior a quatro (4) anos, por conseguinte, existe proibição legal (art. 44, inciso I, do Código Penal). As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não mostram ser ela suficiente para a recuperação dos apelantes. Enfim, não há qualquer requisito legislativo para a imposição da preferência da pena restritiva de direitos ao invés das penas corporais. 8-) Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação. (TJSP; Apelação Criminal 1501023-58.2019.8.26.0189; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Fernandópolis - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/09/2022; Data de Registro: 21/09/2022).

Assim, fica o réu WEMERSON MORAIS DE SOUZA, condenado pelo delito do art. 33, caput, c.c. Art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias meses de reclusão e 655 dias-multa, no menor valor legal.

Regime prisional

Nos termos do quanto preconiza o art. 33, § 2º e alíneas e §3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO.

O réu está preso cautelarmente desde 18/12/2021 (fls. 01). Não obstante, deixo de aplicar o disposto no §2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, uma vez que, mesmo computado o tempo da prisão provisória, não haveria alteração do regime inicial de cumprimento de pena, já que se trata de acusado reincidente e portador de antecedente criminal (com circunstância judicial negativa). Assim, a detração será realizada, no momento apropriado, pelo juízo da execução.

Alternativas penais

Impossível a suspensão condicional da pena, pois o réu não preenche os requisitos objetivos (pena igual ou inferior a 2 anos), nos termos do art. 77 do Código Penal.

Da mesma forma, inviável a substituição por penas alternativas, diante da pena aplicada e reincidência do acusado, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Direito de apelar em liberdade

O réu vem respondendo cautelarmente preso o processo. No presente momento, considerando sua condenação e o regime de pena fixado ao acusado, deve ser mantida a custódia cautelar do acusado. Assim, nego ao acusado o direito de apelar em liberdade.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Recebido eventual recurso promovido por qualquer das partes, extraia-se carta de guia provisória, em favor do réu à Vara das Execuções Criminais competente.

Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, determino:

- a) Lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados.
- b) Apuração dos valores das penas de multa aplicada ao sentenciado.
- c) Comunicação à Justiça Eleitoral que o sentenciado encontra-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.
- d) Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.
- e) Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.
- f) Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 11.690/09, comuniquem-se as vítimas da sentença.
- g) Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, consoante o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 11.719/08, pois não foi possível avaliar com precisão os prejuízos sofridos pelas vítimas, que poderão se socorrer das vias idôneas.
- h) Determino a perda dos valores e bens apreendidos com o acusado, na forma do art. 43 e 45, §3º, ambos do CP.
- i) Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia

acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração, preservada pequena porção para eventual contraprova, com comunicação à Autoridade Policial.

j) Havendo bens ou valores apreendidos, decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, fica autorizada a alienação e destinação do produto ao Funad ou Funpen, conforme o caso, a destruição (reciclagem ecológica) dos bens de baixo valor ou em estado que não permita a sua venda, no caso de quantias em dinheiro, não havendo requerimento de levantamento no prazo de 90 dias, decreto a perda da integralidade do valor, tudo conforme disposto nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dos artigos 516 e seguintes das NSCGJ e ainda do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ. P.I.C.

Aruja, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA